

2012년도 제49회 변리사 제2차 국가자격시험 문제해설

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	디자인보호법	120분	합격을 진심으로 기원합니다.^^	

【A-1】 (30점)

甲은 자동차 휠에 관한 새로운 디자인을 개발하여 2011. 11. 1. 디자인등록출원을 하고 같은 해 11. 15.부터 위 디자인을 적용한 자동차 휠을 판매하기 위하여 甲 자신의 인터넷 홈페이지를 통해 홍보를 시작하였다. 乙은 2012. 4. 1. 자신이 새로 개발한 승용차 디자인을 출원하였는데, 승용차 디자인에는 甲이 출원한 휠과 유사한 형상과 모양을 한 휠이 포함되어 있다. 甲의 출원은 2012. 6. 20. 공개되었다고 할 경우 乙의 승용차 디자인출원은 등록될 수 있는지 여부를 판단하고, 만일 등록된다면 甲과 乙 사이의 법적관계에 대하여 논하시오.

<출 제 평>

본 A-1문항에 대한 구체적 논점을 제시해 드린 후 답안지 작성시 유의점을 중심으로 설명드리겠습니다.

1. 자동차 휠 VS 승용차의 경우 완성품과 부품의 관계인지
2. 부품이 디자인으로 등록 가능한지(부품의 물품성 인정여부)
3. 인터넷 홈페이지를 통해 홍보를 한 것이 공지인지
4. 乙 출원의 등록요건 만족여부(신규성, 창작성, 선출원주의, 확대된 선출원주의)
5. 이용관계 만족여부(성립요건)
6. 이용관계 성립시 甲과 乙사이의 법적관계(허락에 의한 실시 및 통상실시권 하여 심판 중심)

- A-1문항의 경우 완성품과 부품의 문제로서 충분히 올해 출제가 예상된 지문입니다. 수업 시간에도 말씀드렸지만 먼저, 사안의 자동차 휠과 승용차가 부분과 전체관계인지 또는 부품과 완성품의 관계인지에 대한 명확한 관계 정립을 기술해 주시고, 답안을 풀어나가시는 것이 중요하다고 판단됩니다. 왜냐하면 전혀 다른 방향으로 논의가 전개되기 때문입니다.

- 본 사안은 완성품과 부품의 관계로 기재해주시고(甲이 자동차 휠을 인터넷에서 판매를 위해 홍보를 하고 있다는 점에서 독립거래의 대상이 된다고 파악하셔야 합니다.) 다음 목차를 부품도 디자인 등록이 가능한지 여부에 대해 전개해 주셔야 합니다.(이는 사안에서 단지 甲의 자동차 휠 디자인 출원이 공개만 되었다고 전제되어 이러한 공개가 출원공개 신청에 의한 것인지 또는 등록에 의한 것인지 불명확하기 때문입니다.)

- 다음 목차는 甲이 인터넷 홈페이지를 통해 홍보한 것이 공지로 볼 수 있는지 판단해 주셔야 합니다. 다만, 이 경우 특허법과는 달리 디자인은 물품의 미적외관이므로 공지되기 쉬운 점을 언급하시면서 일단은 공지가 되었다고 하셔야 합니다.(공지가 되지 않다고 하기에는 정황이 너무 부족하고 그 다음 논의 전개가 매끄럽지 않기 때문입니다.)

- 또한 다음 목차로는 乙의 등록가능성 즉, 문제되는 등록요건으로 甲의 공지행위로 인한 신규성과 창작성 흠결여부, 甲의 선출원으로 인한 선출원주의 및 甲 출원의 공개로 인한 확대된 선출원주의 만족요부를 꼼꼼하게 검토해 주셔야 합니다. 다만, 여기서 주의하실 점은 부품과 완성품의 관계를 전제한 설명이 반드시 들어가야 하며, 창작성 및 확대된 선출원주의의 경우 결합관계도 아니고 부품 선출원 후 완성품이 후출원되었으므로 적용이 되지 않기 때문에 분량을 적게 기재하시는 것이 타당합니다. 이는 유사판단이 전제되는 등록요건으로서 자동차 휠 및 승용차의 유사판단 내용이 반드시 들어가야 하는 신규성과 선출원주의의 분량이 어느 정도 차지해야 하는 답안내용과 차이점이기도 합니다.

- 상기까지 검토 후 다음 목차로는 甲과 乙의 출원이 모두 등록된 경우의 법적관계 즉, 이용관계에 대한 논점 기재가 필요합니다.(다만, 일부 수험생들 중에는 이 문장에 대해 乙의 출원만 등록되고 甲의 출원이 등록되었다는 지문이 없어 이를 이용관계라고 생각하지 않으시는 분들이 있어 안타까웠습니다. 문제를 잘 읽어보시면, 甲의 출원이 2012.6.20에 공개되었다고 했고 디자인보호법 특성상 신청에 의한 출원공개제도만이 존재하는 상황에서 사안에서 아무런 근거도 없이 甲이 신청하여 공개되었다고 보기는 무리가 있을 듯 합니다. 따라서 본 사안은 甲과 乙의 출원 모두가 등록되었다고 판단해주셔야 합니다.) 이용관계에 대한 의의, 취지 및 일반론과 더불어 이용관계에 대한 학설대립은 물론 성립요건에 대한 검토가 반드시 들어가야 합니다.

- 상기에서 이용관계가 성립한다고 검토하시고 이하에서는 이용관계 성립시 甲과 乙간의 법적관계 즉, 허락에 의한 실시 및 통상실시권 허여심판을 기본 내용으로 하여 적극적 효력의 제한과 위반자의 책임, 그리고 보론으로 크로스라이센스까지 적으시면 플러스 점수가 예상됩니다.

상기의 각 논점에 대한 답안지 기재시 유의사항을 보셨습니다. 본 문제의 핵심은 사례형 문제라는 점을 절실히 느끼셔서 자신이 아는 지문인 완성품과 부품, 이용관계의 내용만을 외운데로 기재하시는 것은 지양하셔야 합니다. 즉, 답안 논리가 무엇보다 중요한 문제라고 사료됩니다.

<예 시 답 안>(이하 예시답안 작성시 구체적인 내용은 생략합니다.)

Ⅰ. 문제의 제기

다른 주체인 甲과 乙의 출원 물품간의 관계를 규명하고, 이를 기초로 양 출원의 선·후에 따른 선출원주의 및 신규한 디자인만을 보호하려는 법목적 실현을 위한 신규성, 창작성, 확대된 선출원주의를 중심으로 乙 출원의 등록가능성에 대하여 검토한 후, 만일 甲과 乙의 출원 모두가 등록될 경우 이용관계 성립여부 및 성립시 양자의 법적관계에 대하여 논하겠다.

Ⅱ. 자동차 휠과 승용차의 관계 및 부품의 디자인 등록 가능여부

1. 완성품과 부품(의의, 구별)->완성품과 부품의 관계이다.

2. 부품인 자동차 휠의 디자인 등록 가부

(물품성과 관련하여 문제->학설(호환형식성설, 호환가능성설)->판례(호환가능성설)->검토(물품의 범위를 넓게 해석하여 호환가능성설에 따라 부품으로 인정))

Ⅲ. 乙 출원의 등록가능성

1. 신규성 흠결여부

(의의, 취지, 홍보가 공지에 해당하는지(전기통신회선에 의한 공지) 흠결시 효과, 사안 포섭 후 부품 공지 후라도 완성품디자인의 전체 미감을 결정하는 요지가 아닌 경우 신규성 만족)

2. 창작성 흠결여부

(의의, 취지, 흥결시 효과, 사안 포섭 후 용이창작 불가능하여 창작성 인정)

3. 선출원주의 흥결여부

(의의, 취지, 흥결시 효과, 사안 포섭 후 비유사한 디자인으로 선출원주의 만족)

4. 확대된 선출원주의 흥결여부

(의의, 취지, 흥결시 효과, 사안 포섭 후 부품 먼저 출원 된 사안으로 적용없어 확대된 선출원주의 만족)

5. 소결

乙 출원은 등록가능, 이하 甲과 乙의 출원이 모두 등록되었다는 전제하에 이용관계 성립 여부 및 성립시 양 자의 법적관계에 대하여 검토한다.

IV. 甲과 乙 사이의 이용관계 성립여부 및 성립시 법적관계

1. 이용관계 성립여부

(1)이용관계(의의, 취지, 법적개념(학설, 판례 검토))

(2)이용관계 성립요건

(3)이용관계 성립태양

(4)소결-부품과 완성품의 관계로서 성립요건 모두 만족하여 이용관계 성립

2. 甲과 乙 사이의 법적관계

(1)이용관계 관련 규정의 특징-선원권리자 보호 및 후원권리자 실시확보 위한 규정이 있다.

(2)적극적 효력의 제한-①제45조 ②제70조 ③위반자의 책임

(3)보론- 만일 본 사안에서 甲이 乙의 등록 승용차디자인의 실시가 필요한 경우 乙의 통상실시권하여 심판에 의한 통상실시권 하여 후, 甲도 乙에게 역으로 선택의 후 불성립시 통상실시권하여심판을 청구할 수 있다.

V. 사안의 해결

(1) 물품의 외관보호를 목적으로 하는 디자인보호법 특성상 부품과 완성품의 관계는 포함관계이므로 출원 중 및 등록 후에도 법적관계가 발생

(2) 이용관계 확인을 위해 甲은 乙의 승용차 디자인 실시를 전제로 적극적권리범위 확인심판도 청구할 수도 있다.(判-플러스 점수)

【A-2】 (20점)

직물지의 등록디자인 A와 디자인 B는, 디자인의 이면은 모두 아무런 모양이 없는 점에서 동일하다. 그러나 그 표면에 있어서 등록디자인 A는 여러 가닥으로 된 실 형상의 선들이 아래로 내려오면서 서로 꼬이듯이 보이도록 한 'V'자 모양을 상하좌우로 연속적으로 반복하여 이루어져 있는 반면, 디자인 B는 등록디자인 A와 유사한 바탕 모양에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈려 반복하여 이루어져 있고 황색 계통의 색으로 채색되어 있어서, 양 디자인은 전체적으로 볼 때 서로 유사하지 아니하다. 그런데 디자인 B는 위 등록디자인 A의 위 'V'자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 하나의 디자인을 형성하고 있어서 등록디자인 A의 본질적 특징인 위 'V'자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있다. 디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 포함되는지 여부에 대하여 논하시오.

--

<출 제 평>

본 A-2문항에 대한 구체적 논점을 제시해 드린 후 답안지 작성시 유의점을 중심으로 설명드리겠습니다.

1. 디자인의 보호범위(원칙-제41조, 예외-유사디자인, 간접침해 등)
2. 디자인의 유사판단(전체관찰 중심, 요부(요지)관찰의 참고)
3. 디자인 B가 등록디자인 A를 이용하는지 여부
4. 디자인 B가 등록디자인 A를 그대로 포함하는지 여부
(판례 적시 후 자신의 판례에 대한 평가가 꼭 들어가야 함.)

- A-2 문항의 경우 판례의 사안이 그대로 출제된 사안입니다. 나눠드린 자료에 보시면 특허법원의 판단을 대법원에서 파기환송 시킨 사안으로서 본 판례 사안은 수험가에서는 출제 지문으로 유사판단 및 이용관계와도 관련논점으로 출제가 예상되었던 문제였으나, A-1문과 비슷한 논점이 출제되어 수험생들이 논점을 파악하는데 어려움이 있었다고 사료됩니다.

- 또한, 본 대법원 판례 사안에 대한 내용만을 알고 원심인 특허법원의 태도를 알지 못해, 분량을 채우시지 못하게 핵심논점인 판례 내용 대신 디자인의 유사판단 및 이용관계에 대한 단문을 위주로 기재하신 수험생들이 많아 안타까웠습니다.

- 상기 논점을 보시더라도, 디자인보호법상 물품의 미적외관을 보호대상으로 하여 권리범위가 협소하므로 적절한 디자인보호를 위해 보호범위는 유사범위까지 인정(법적근거 法제41조)한다는 내용과 보호대상의 특성에 따라 선행디자인을 그대로 포함하여 이용하는 디자인도 발생할 수 있다는 점을 명시하신 후 이것도 권리범위에 포함된다는 내용을 기재해주셔야 합니다.->다음으로 유사범위 판단에 대한 명확한 기준이 없어, 학설 및 심사기준과 판례가 많이 있는바 이에 따른 사안의 검토 및 이용하는지 여부에 대하여 이용관계에 관한 학설에 따라 검토한 후->결론으로 본 사안과 관련한 판례의 태도를 특허법원과 대법원입장의 판례요지를 중심으로 고찰하여 자신의 판례에 대한 평가와 함께 사안을 포섭하신 후 ->디자인 B가 등록디자인 A의 권리범위에 포함되는지 여부를 결론내리시면 되는 문제였습니다. 이와 같은 논리적 흐름을 따르셔야 고득점이 가능하다고 봅니다. 특히 본 사안과 같이 판례 사안이 그대로 출제된 경우 출제자는 보통 수험생들의 사건 히스토리를 제대로 이해하고 있는지를 알고 싶어함이 대다수입니다. 따라서 사안에 대한 특허법원 및 대법원 판례의 요지까지 언급하시면 매우 좋은 인상을 줄 수 있는 문제였다고 사료됩니다.(첨부자료 참고)

<예 시 답 안>**I. 문제의 제기**

디자인보호법은 물품의 미적외관을 보호대상으로 하므로 권리범위가 협소하여 유사범위까지 보호범위로 인정하고 있고, 전체적으로 비유사하더라도 등록디자인을 이용하는 관계의 디자인도 권리범위에 속한다. 따라서 사안의 직물지 디자인 A와 B가 유사한지 여부를 판단하고 디자인 B가 등록디자인 A를 이용하는 관계에 있는지 여부도 검토한다.

II. 등록디자인의 권리범위(분량을 고려 간단히 축약해서 언급하셔야 하는 부분입니다.)

1. 제41조(원칙)
2. 유사판단에 대한 견해(학설, 심사기준, (判)전체관찰 원칙, 요부관찰 보충)
3. 소결-직물지 디자인 B와 등록디자인 A는 전체적으로 비유사. 따라서 이하 이용하는 관계인지 여부를 구체적으로 검토한다.

III. 디자인 B가 등록디자인 A를 이용하는 관계에 있는지 여부

1. 이용관계의 의의, 취지(양자 모두 등록되지 않아도 이용하는 관계가 성립될 수 있음)
2. 이용관계의 법적개념(그대로설이 타당)
3. 소결(디자인 B가 등록디자인 A에 그대로 포함되었는지 여부가 문제-> 이하 검토)

IV. 디자인 B가 등록디자인 A에 그대로 포함(도입)되었는지 여부

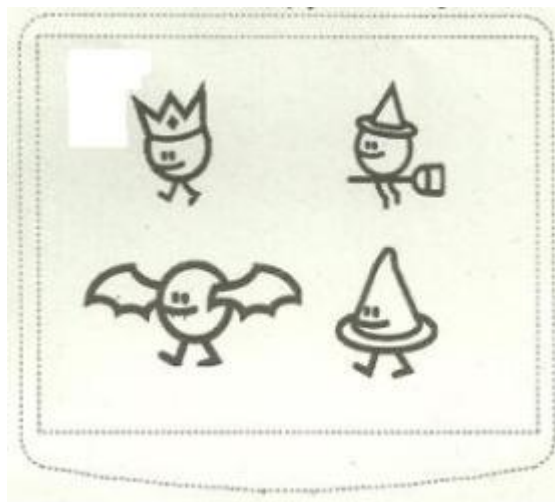
1. 이용관계에 대한 판례의 기본적 태도
2. 본 사안에 대한 특허법원의 태도-판례요지를 중심으로 기재(배부자료 참고)
3. 본 사안에 대한 대법원의 태도-판례요지를 중심으로 기재(배부자료 참고)
4. 소결-판례에 대한 자신의 평가(예-보호대상의 특성 및 권리범위의 협소를 고려하여 전체적으로 비유사하더라도 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 이용하는 관계에 있다는 대법원 태도가 타당. 다만 사안은 본질적 특성이 손상되었으므로 그대로 도입되어 있다고 보기 어려움)

V. 사안의 해결

- (1) 디자인 B와 등록디자인 A는 전체적으로 비유사하고, 디자인 B가 등록디자인 A를 그대로 포함하고 있다고 볼 수 없으므로 디자인 B는 등록디자인 A의 권리범위에 포함되지 않는다.
- (2)(보론)디자인에 대한 유사개념에 대해 명확한 개념 정립 필요, 권리범위에 속하는지 여부에 대해 권리범위확인심판을 통해 미리 확인을 받아두는 것이 추후 분쟁해결에 유리(플러스점수)

【B-1】 (30점)

甲은 휴대폰 제조업자로서, 자신의 스마트폰 화면에서 사용할 독특한 캐릭터 이미지들을 창작하고, 디자인의 대상이 되는 물품을 “화상디자인이 표시된 휴대폰”으로 하고, 아래 그림과 같이 정면도를 작성하여 디자인심사등록출원을 하였다. 그 후, 특허청으로부터 출원디자인에 대하여 등록을 허여할 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 받았다. 상기 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 예측하고, 이를 극복하기 위한 대응 방안을 논하시오.

**<출 제 평>**

본 B-1문항에 대한 구체적 논점을 제시해 드린 후 답안지 작성시 유의점을 중심으로

설명드리겠습니다.

1. 화상디자인에 대한 보호여부
2. 화상디자인 출원시 구체적인 거절이유
 - (1)무심사등록출원(法제9조 제6항)
 - (2)1디자인 1출원주의(法제11조 제1항 및 제2항)
 - (3)공업상 이용가능성(法제5조 제1항)
 - (4)부분디자인 취지 기재
3. 극복방안
 - (1)보정(변경보정)
 - (2)분할(형태적 일체성 불인정시)
 - (3)부분디자인 취지기재
 - (4)복수디자인등록출원

- 본 B-1의 주논점은 상기와 같습니다. 다만 본 문제는 수업시간에 강조드렸던 화상디자인에 대한 논점이기는 하나, 구체적으로 단문을 옮기는 것이 아닌 최신 출제 경향에 맞도록 사례화 되어 구체적인 거절이유를 찾는 문제와 그에 대한 대응방안을 논하는 형태로 출제되었습니다. 상기 논점에서 보실 수 있듯이 본 문제의 거절이유는 사안에서 구체적으로 찾을 수 있는 거절이유가 있는 반면, 명확하지 않은 사항도 함께 포함되어 있습니다. 30점짜리 문제의 분량을 고려할 경우 상기와 같은 숨은 논점(부분디자인 취지 기재 및 출원 후 취지 기재가 요지변경인지 여부)도 찾아내셔야 하는 문제입니다.

- 본 문항의 논리적 흐름은 먼저 화상디자인의 보호대상여부(종래 공업성 인정여부 논란)->보호대상이 되므로 출원이 가능하여 거절이유를 받음. 거절이유의 예측->이를 극복하기 위한 대응방안의 목차흐름으로 답안을 작성하셔야 할 것입니다.

- 올해 디자인보호법 시험은 출제자가 본 문제에서 수험생 간의 변별력을 두고자 하지 않았나 사료됩니다. 즉, 전형적인 특유디자인에 대한 문제 방식이 아닌 구체적 화상디자인의 형태를 제시해주고 그에 따른 거절이유까지 예측해야하는 문제로서 다른 문제와 달리 난이도가 있다고 평가됩니다. 다만, 논점을 찾으실 때 화상디자인은 부분디자인으로 출원됨을 전제로 하는 점을 간과하신 분들이 있어 안타까웠습니다.

- 본 문제의 구체적인 거절이유로는 심사등록출원이 되었으므로 무심사등록출원 물품은 무심사등록출원되어야 한다는 제9조 6항을 중심으로 기재하시되, 제시된 화상디자인을 자세히 보시면 각 캐릭터마다 분리 표현되어 있기 때문에, 형태적 일체성을 판단하셔서 제11조 1항의 논점도 주논점으로 보실 수 있습니다. 또한, 정당한 물품명의 기재와 관련한 제11조 2항과 정면도만을 첨부한 것과 관련한 공업상 이용가능성도 어느 정도 언급이 필요한 논점이었습니다. 다만, 부분디자인 여부란의 기재에 관한 내용은 본 문제의 논의가 전개되기 위한 전제가 되는 부분이므로 꼭 기재를 해주셔야 한다고 사료됩니다. 또한 보정에 있어서도 부분디자인 취지를 기재하지 않고 출원 후 부분디자인 취지를 기재한 보정의 경우 그 보정은 도면의 디자인의 설명란의 기재 및 도면 등의 구체적인 표현에 의해 당해 출원이 부분디자인에 관한 것임을 명확히 알 수 있는 경우에 요지변경이 아닌 것으로 볼 수 있다는 내용을 기재한 수험생들을 찾을 수 없어 안타까웠습니다.(노태정 기본서 p328(2007년 개정판 기준), 부분디자인의 출원절차 중 출원의 보정과 요지변경 부분 참조.)

- 극복방안의 경우에도 무심사등록출원으로의 변경보정을 중심으로 기재해주시고, 사안의 화상디자인에 대한 구체적 캐릭터간 형태적 일체성을 판단하시어 이에대한 판단과 불인정시 11조 1항의 위반으로 분할출원이 가능하다고 기재하시는 것이 주논점으로 사료됩니다. 추가적으로 실체보정의 인정여부와 상기 말씀드린 부분디자인 취지기재 등의 부논점이

있습니다.

<예 시 답 안>

Ⅰ. 문제의 제기

디자인보호법은 물품의 미적외관을 보호대상으로 하는바 물품이 전제되어야 하므로 원칙적으로 화상디자인은 디자인 대상이 되지 않는다. 다만, 정보통신기술의 발달에 따른 시대적 흐름을 고려하여 이에 대한 보호대상 여부를 검토하고, 사안의 甲의 출원 디자인의 예상되는 거절이유를 예측한 후, 이에 대한 극복방안을 논하겠다.

Ⅱ. 화상디자인의 보호대상 여부

1. 화상디자인의 의의·취지 및 연혁(연혁은 꼭 써주셔야 하는 부분입니다.)
2. 보호여부 및 보호대상
3. 소결-2003년 7월 1일 시행심사기준 보호대상. 사안은 휴대폰으로서 보호대상에 포함 즉, 디자인의 대상으로 출원 가능.

Ⅲ. 甲의 출원의 예상되는 거절이유

1. 무심사등록출원(法제9조 제6항)
2. 협의의 1디자인 1출원주의(法제11조 제1항)
3. 공업상이용가능성(法제5조 제1항)
4. 정당한 물품명의 기재(法제11조 제2항)
5. 부분디자인 취지 기재(法제5조 제1항)

Ⅳ. 甲의 상기 거절이유를 극복하기 위한 대응 조치

1. 보정
 - (1)변경보정(의의, 취지, 사안의 경우-심사등록출원을 무심사등록출원으로 변경하는 보정이 가능하다.)
 - (2)실체보정(의의, 취지, 사안의 경우-도면의 기재사항에 대한 액정화면을 제외한 부분에 대해 요지변경이 되지 않는 범위에서 실선으로 도시해야하고, 이에 따른 특정방법에 대해서는 디자인의 설명란에 기재하여야 한다.)
 - (3)삭제보정(제11조 제1항 위반의 경우 삭제보정으로 하나의 화상디자인만을 등록받을 수 있다.)
2. 분할
 - (1)화상디자인 캐릭터가 각각 분리되어 있는 경우 형태적 일체성이 없으면 제11조 제1항 위반이며, 이 경우 각각의 형태에 대하여 분할출원으로 극복이 가능하다.
 - (2)분할출원시에는 디자인무심사등록분할출원을 하여야 하며, 이 경우 원출원에서 삭제보정의 조치가 병행되어야 한다.
3. 복수디자인등록출원으로서의 보정

상기 무심사등록출원으로서의 보정 후 제11조 제1항의 위반인 경우, 복수디자인등록출원으로서의 보정도 가능하다. 다만 도면을 추가 제출해야 할 경우 요지변경일 가능성이 크므로 취하 후 복수디자인등록출원하는 것이 타당하다.

Ⅴ. 사안의 해결

- (1)상기 甲은 거절이유에 맞는 대응조치로 화상디자인의 등록을 도모하는 것이 타당하나, 절차가 보다 간편한 보정으로 극복을 하는 것이 바람직하다.
- (2)또한 화상디자인은 부분디자인을 전체로 하며, 전체디자인으로 등록받는 것보다 추후 권리범위에 있어 출원인에게 유리하다.(플러스 점수)

【B-2】 (20점)

甲은 디자인 A를 창작하여 이를 법적으로 보호받고자 한다. 그런데 디자인은 모방이 매우 용이하다는 특징이 있어 디자인 A를 법적으로 제대로 보호받을 수 있을지 걱정이다. 甲이 이용할 수 있는 디자인 보호법상 디자인권 침해의 방어적 제도를 논하시오.

<출 제 평>

본 B-2문항에 대한 구체적 논점을 제시해 드린 후 답안지 작성시 유의점을 중심으로 설명드리겠습니다.

1. 유사디자인제도
2. 비밀디자인제도
3. 출원공개제도
4. 등록디자인의 표시

- 침해와 관련되어 올해도 여지없이 출제가 되었습니다. 다만, 본 문항의 경우 전형적인 침해유형이 아닌 침해와 관련된 제도에 대해서 묻는 단문형 문제로 기출이 되었습니다.

- 이러한 단문의 경우, 즉 모방이 ‘매우’ 용이하다는 지문에 너무 집중하신 나머지 비밀디자인제도만을 주논점으로 파악하여 작성하신 분이 의외로 많아서 안타까웠습니다. 제 수업시간에 항상 침해문제의 사안의 해결부분에 써주었던 내용 즉, 노태정 변리사님 기본서에 있는 내용을 그대로 발췌한(노태정 기본서 p707(2007년 개정판 기준), 제3절 ‘디자인권 침해의 방어적 제도’) 부분이 단문형태의 문제로 출제되어, 평소 4가지 단문에 대한 축약서술을 준비하신 수험생분들에게 유리한 문제였다고 사료됩니다.

- 재차 강조 드린 부분으로 제가 수업시간에 말씀드린 ‘가장’이라는 말이 사안에서는 분명히 없음에도 불구하고, 이를 각각 5점씩의 분량을 채워야 함에도(단, ‘등록디자인의 표시’의 경우 요건 및 절차가 따로 없으므로 이 내용은 3점 정도가 적당하다고 판단됩니다.), 비밀디자인제도만을 주논점으로 생각하여 약10점 이상의 분량으로 쓰신 수험생들이 많아 안타까웠습니다. 또한 문제 말미에 ‘논하시오’라는 말에 집중하시면 더더욱 본 문제는 여러 가지 제도가 주논점이 될 수 있다라는 점을 파악하실 수 있었을 것입니다. 다만 기재하실 때에는 출제의도에 착안하여 취지를 구체적으로 기재하여 주시는 것이 중요하고 본 제도 이용시 왜 디자인권 침해의 방어적 제도인지와도 관련지어 기재해 주시는 것이 중요하다고 판단됩니다.

<예 시 답 안>**I. 서설**

디자인은 물품의 미적외관이므로 타인의 모방이 용이하고 유행에 좌우되어 적절한 디자인의 보호를 위한 제도를 두고 있다. 따라서 이하 A 디자인 창작자인 甲이 창작 디자인의 적절한 보호를 위해 디자인보호법상 이용할 수 있는 제도로써 유사디자인, 비밀디자인, 출원공개, 등록디자인의 표시 등에 대해서 검토한다.

II. 유사디자인제도(法제7조)

1. 의의 및 취지
2. 등록요건 및 절차

3. 유사디자인권의 효력(法제42조)

4. 소결

디자인권의 효력은 등록디자인 뿐만 아니라 이와 유사한 디자인에도 미치나, 범위가 불명확하여 디자인보호법은 유사디자인제도를 인정하고 있으며, 이에 따라 자신의 기본디자인에 유사한 디자인을 미리 등록받아 두면 권리침해를 미연에 방지할 수 있는 효과가 있어 디자인권 침해의 방어적 제도라고 할 것이다.

III. 비밀디자인제도(法제13조)

1. 의의 및 취지

2. 요건 및 절차

3. 효과

4. 소결

물품의 미적외관 보호를 목적으로 하는 디자인보호법 특성상 디자인권자 보호를 위해 디자인권자의 청구에 의한 일정기간동안 비밀로 할 수 있도록 하는 비밀디자인제도를 두고 있어 모방침해 방지 및 사업시기 조정 등의 효과가 있어 디자인권 침해의 방어적 제도라고 할 것이다.

IV. 출원공개제도(法제23조의2)

1. 의의 및 취지

2. 요건 및 절차

3. 효과

4. 소결

출원공개제도는 출원인의 신청에 의하여 출원을 공개 할 수 있도록 하여, 출원된 디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시한 자에게 경고 후 보상금청구권을 발생하도록 하는 효과가 있어 이 또한 디자인권 침해에 대한 방어적 제도라고 할 것이다.

V. 등록디자인의 표시(法제79조)

1. 의의 및 취지

2. 타법의 경우

3. 소결

디자인권자는 등록디자인에 대한 물품 또는 그 물품의 용기나 포장 등에 디자인등록의 표시를 할 수 있다. 판매품에 디자인등록의 표시를 함으로써 침해를 미연에 방지할 수 있고 또 디자인등록의 표시는 침해행위의 과실의 추정을 강화하는 효과가 있어 디자인권 침해에 대한 방어적 제도라고 할 것이다.

VI. 결어

(1)디자인 창작자는 출원 중에는 유사디자인 출원, 비밀디자인제도 신청 및 출원공개 신청 등으로 방어가 가능하고, 디자인권 등록 후에는 디자인권 행사는 물론 방어적으로 유사디자인권, 비밀기간의 연장, 보상금청구권 행사 및 등록디자인의 표시 등의 조치를 취할 수 있다.

(2)최근 디자인보호법 전문 개정안이 논의 중이다. 개정안 중 물품의 확대 및 한 벌의 물품 디자인 및 복수디자인출원의 성립요건 완화, 유사디자인제도의 폐지 및 관련디자인제도의 도입, 디자인 존속기간의 20년까지의 연장 등도 디자인 창작자의 적절한 보호를 위한 일환으로 볼 수 있을 것이다.(플러스 점수)